

1500572-42.2022.8.26.0540
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/05/2022
... 16.02.07).

Em relação ao crime de tráfico, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

No tocante ao furto, o conjunto probatório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500572-42.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500572-42.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCELO EDUARDO DE CAMPOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

MARCELO EDUARDO DE CAMPOS foi denunciado por incursão no caput do art. 155 do Código Penal e no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Narra a denúncia que, no dia 23 de março de 2022, por volta das 10 horas, em uma Viela com acesso pela Rua Caiena, Parque das Américas, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado, vendeu, trazia consigo e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 16-7, laudo de constatação de fls. 21-3 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 85-7, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que no dia 23 de março de 2022, pouco após às 10 horas, na rua Vicente de Carvalho Bruno, 1142, Parque das Américas, nesta cidade e comarca de

Mauá, o acusado, subtraiu, para si, o aparelho celular Samsung A10S, avaliado em R\$ 800,00 (fls. 30), pertencente a Maria Quitéria da Silva Oliveira.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl.116) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteia a absolvição, ou, ao menos, a fixação das penas nos patamares mínimos, reconhecendo-se a atenuante da confissão, além da fixação de regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 11-5), auto de exibição e apreensão (fls. 16-7), fotografias (fls. 24-7), auto de reconhecimento do objeto (fl. 28), auto de avaliação (fl. 30), laudo de constatação (fls. 16-8), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 85-7) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu negou as acusações (fls. 09-10).

Sob o contraditório, admitiu o tráfico, porém negou o furto. Disse que pegou o telefone da vítima para ligar para sua família, mas quando visualizou os policiais largou o aparelho na própria escada da residência da ofendida (mídia digital).

Tal versão não se mostra razoável.

A vítima Maria Quitéria, na fase administrativa, informou que (sic) "estava no quintal de sua casa dando comida para o cachorro na lavanderia, momento em que ouviu um barulho vindo do telhado da casa de seu vizinho, sendo que ao olhar para ver o que estava acontecendo, viu um indivíduo no telhado da casa de seu vizinho, algemado com as mãos para a frente; Que, este indivíduo pulou na lavanderia da casa da declarante, onde ela se encontrava, e apresentava arranhões em suas pernas; Que, o indivíduo, muito alterado, sentou no meio da escada e pediu um martelo para que pudesse quebrar a algema; Que, a declarante respondeu que não tinha, então o indivíduo pegou uma chave de fenda que estava no muro da escada e tentou quebrar a algema, porém, como não conseguiu, ficou nervoso e pediu alguma coisa mais pesada para tentar quebra-la, contudo, neste ínterim, a declarante escutou alguém batendo em seu portão dizendo: "polícia, polícia", então desceu a escada correndo e abriu o mesmo; Que, no momento em que os policiais entraram no quintal, o indivíduo pulou o muro para a casa de outro vizinho, não presenciando o momento em que foi detido pelos policiais; Que, a declarante ao procurar seu telefone celular da marca Samsung, Galaxy A10S, que estava sobre a máquina de lavar, percebeu que o mesmo não estava lá, então a declarante pegou o telefone de seu filho que estava no interior de sua casa e ligou para seu número de telefone (11) 99135-0302, porém, era direcionado para a caixa postal; Que, a declarante foi orientada pelos policiais a se dirigir até esta distrital para ser registrada a ocorrência sobre os fatos, sendo que aqui chegando, foi informada pelos policiais que após Marcelo Eduardo de Campos, indivíduo que pulou em sua casa, pulou da casa da declarante para o telhado da casa do vizinho, este jogou um telefone no referido telhado e continuou a fugir, sendo ainda que pensaram que o referido telefone era de propriedade dele e não da declarante; Que, ao ser exibido o referido telefone celular acima citado, a

declarante o reconheceu, com 100% de certeza, como sendo seu telefone que Marcelo subtraiu de sua casa que estava sobre a máquina de lavar, tendo em vista a senha para abrir o mesmo e as fotos e aplicativos constante neste" (fls. 07-8).

Os policiais militares, na fase inquisitiva, historiaram que (sic) "aproximadamente no meio de sua extensão existe uma viela que dá acesso a uma comunidade, conhecido ponto de venda de entorpecentes como BIQUEIRA BUENO AIRES; Que, abordo de viatura descaracterizada, estacionaram em ponto estratégico nas proximidades, onde realizaram campana por aproximadamente 15 minutos, de onde podiam observar a entrada da viela e consequentemente a movimentação de pessoas, sendo que avistaram também um indivíduo de cor parda, bermuda clara que estava sentado em um sofá com um estojo de lápis em mãos; Que, observaram que cerca de três pessoas, em momentos distintos, adentraram a viela, se aproximavam de tal indivíduo no sofá, lhes entregava algo, e este guardava no estojo, pegava algo no mesmo e entregava a tais pessoas que saíam apressadamente do local; Que, em momento oportuno, com apoio de outros Policiais desta unidade policial, desembarcaram e promoveram a incursão naquela viela, sendo que se aproximaram do indivíduo que estava sentado no sofá com o estojo em mãos e se identificaram como policiais e, este foi identificado como Marcelo Eduardo de Campos, não esboçou qualquer reação; Que, ao ser questionado sobre o que fazia ali, Marcelo alegou que somente iria levar o estojo que segurava para um indivíduo no final da referida viela, porém, não havia ninguém no final a mesma; Que, em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em suas vestes, porém, dentro do estojo continha a quantia de R\$ 126,00, e 21 invólucros transparentes com substancia branca análoga a cocaína, 09 invólucros plásticos com substancias esverdeadas, análoga a maconha e 94 microtubos translúcidos com substancia fragmentada amarelada análoga a crack; Que, diante dos fatos, foi exarada voz de prisão para Marcelo, sendo este algemado com as mãos para trás, pois aparentava muito nervosismo, porém, quando estavam conduzindo Marcelo para a viatura, este desvencilhou-se do depoente e de seu parceiro e saiu em desabalada carrera; Que, diante disso, foram ao seu encalço, contudo, Marcelo conseguiu passar suas mãos algemadas para a frente, pulou um muro de uma casa e continuou a fugir pulando por diversos telhados das casas, sendo que em determinado momento, pulou em um telhado que quebrou, então pulou para uma outra casa e permaneceu na mesma, então o depoente e os policiais dirigiram-se até esta última casa e bateram no portão, sendo atendidos por Maria Quitéria da Silva Oliveira, a qual franqueou suas entradas, porém, quando o indivíduo que estava sentado na escada os viu, saiu correndo e pulou novamente o muro para a casa de um vizinho, sendo seguido novamente pelo depoente, que presenciou quando Marcelo jogou no telhado do vizinho um telefone celular, sendo que após alguns metros, conseguiu deter Marcelo com o apoio do policial Anderson e de demais policiais; Que, após alguns minutos, já na condução de Marcelo para a viatura, surgiu a Sra. Maria Quitéria dizendo que seu telefone celular que estava sobre sua máquina de lavar havia sido subtraído, porém, como o depoente e os policiais acharam que o telefone que Marcelo dispensou era de sua propriedade, orientaram Maria a se dirigir a esta distrital para formalizar a ocorrência sobre os fatos; Que, já nesta delegacia, Marcelo ao ser questionado sobre o telefone celular, negou ser de sua propriedade e, após a chegada da Sra. Maria, lhe foi exibido o referido telefone, o qual imediatamente reconheceu como sendo de sua propriedade, sendo que para tanto, abriu o mesmo com sua senha e mostrou fotos e seus dados pessoais constantes neste, sendo que ao ser novamente indagado sobre o telefone, Marcelo negou que tinha subtraído o mesmo" (fls. 03-6).

Durante a instrução, o policial civil Ulisses reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido. Confirmou que o réu foi visto em local conhecido como ponto de tráfico, praticando atos típicos de venda, bem como que, durante a fuga, dispensou um telefone celular em cima de um telhado. Após a detenção do acusado, souberam que este telefone celular pertencia à vítima. Questionado pelo Defensor, esclareceu que ao ingressar na casa da vítima, o réu estava no quintal da residência, contudo, ao pular o muro, ele jogou o telefone em cima de um telhado (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Em relação ao crime de tráfico, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

No tocante ao furto, o conjunto probatório produzido sob o contraditório, notadamente a palavra da vítima e das testemunhas, autoriza o desate condenatório.

Restou evidenciado que, durante a fuga, o réu entrou na residência da ofendida, apossou-se do seu aparelho celular, que estava em cima da máquina de lavar e, deixou o local na posse do bem. Após pular o muro da residência, Marcelo dispensou o aparelho em um telhado.

A versão do réu de que queria o aparelho para ligar para sua família, durante uma perseguição policial, não é crível.

Não há que se falar em atipicidade da conduta. Caracteriza-se o furto de uso, de acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, "com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem", o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. 2. De acordo com os autos, não há elementos que apontem para a ausência de intenção de apossamento definitivo do bem por parte do acusado, razão pela qual a condenação por furto foi mantida pelo Colegiado estadual. 3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para sustentar o édito condenatório, o que inviabiliza a desconstituição de tais conclusões em sede de recurso especial, já que, para tanto, seria imprescindível o reexame de fatos e provas. Tal providência, porém, é vedada em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 5/3/2018) g.n.

Dessa forma, presentes a materialidade e autoria dos delitos, de rigor a condenação.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do crime de tráfico de drogas 1/5 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (certidão de fl. 58 - proc. 0027482-16.2013 c/c informações da FA fls. 66-8) e da considerável quantidade de drogas apreendida - 94 porções de crack (15,5 gramas), 21 porções de cocaína (15,4 gramas) e 9 porções de maconha (37,5 gramas) - fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Para o crime de furto, majora-se a reprimenda em apenas 1/6, pelos maus antecedentes, atingindo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e crack apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Ainda, quanto a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na fase intermediária, aumento as reprimendas do réu em mais 1/6, diante da reincidência (certidão de fl. 59 - proc. 6330-93.2015 c/c informações da FA fls. 66-8), totalizando 07 anos de reclusão e 700 dias-multa para o crime de tráfico e 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa para o crime de furto.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, em relação ao crime de tráfico, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, em plena traficância e em poder dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve,

tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra: 'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do

contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des.

Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era mesmo o caso de reconhecimento da confissão, já que parcial e não foi utilizada para convencimento do Juízo, que fundamentou: "não incidência da confissão em relação ao réu Rodrigo, uma vez que ao negar a participação dos corréus Wallace e Paulo, pretendeu ludibriar o Juízo, faltando com a verdade". Assim, a admissão parcial do fato não foi utilizada para formação de convicção do D. Juízo sentenciante, que se limitou a transcrever a versão dada pelos acusados, valendo-se, para se inclinar pela condenação, dos relatos da vítima, dos agentes policiais e da adolescente." (TJSP, Apelação Criminal nº 0013449-58.2017.8.26.0348, Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. 9 de março de 2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravamento regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRG no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 2. Agravamento regimental desprovido. (AgRG no HC 613736/RJ, QUINTA TURMA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. em 30/03/2021, DJe 13/04/2021).

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Tratando-se de réu reincidente, não incide o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, somam-se as penas que totalizam 08

anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e 712 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo.

O réu, reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu MARCELO EDUARDO DE CAMPOS, qualificado nos autos, a cumprir pena de 08 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 712 dias-multa, no patamar mínimo, por incursão no caput do art. 155 e caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Denego ao réu o apelo em liberdade, mantidos os fundamentos da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a incineração das substâncias entorpecentes e estojo apreendidos (fls. 16-7), nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei nº 11.343/06, bem como oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores apreendidos (fls. 90) ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA